

论文编号	
------	--

中国政法大学“中伦杯”
第二十二届“学术十星”论文大赛参赛论文

信托受托人谨慎义务的规范构造与适用径路

信托受托人谨慎义务的规范构造与适用径路

【摘要】

受托人谨慎义务具有丰富的理论内涵与实践价值，但是面临着理论不清与适用困难的双重困境。就规范属性而言，基于经济与道德的法理基础，受托人谨慎义务呈现出任意性与强制性耦合的面向。就规范内容而言，受托人谨慎义务呈现出阶层式构造，按照适用顺序可分为意定性规范、强制性规范与任意性规范，分别对应与具体的信托文件条款、信托法一般条款与信托行业规范性文件。就规范适用而言，受托人谨慎义务规范群应当结合法学方法论论证说理，明确各个规范的适用顺序，正确运用具体化与权衡来适用法律原则，才能加强受托人谨慎义务裁判的正当性与稳定性。

【关键词】 受托人 谨慎义务 阶层构造 法律原则

THE NORMATIVE CONSTRUCTION AND APPLICATION OF THE DUTY OF CARE OF TRUSTEES

【ABSTRACT】

The trustee's duty of care has rich theoretical connotation and practical value, but faces the double dilemma of unclear theory and difficult application. In terms of normative attributes, based on economic and moral jurisprudence, the fiduciary duty of care presents the coupling of arbitrariness and mandatory orientation. In terms of normative content, the trustee's duty of care presents a hierarchical structure, which can be categorized into intentional norms, mandatory norms and arbitrary norms according to the order of application, corresponding to the provisions of specific trust documents, general provisions of the trust law and normative documents of the trust industry. As far as the application of norms is concerned, the normative cluster of fiduciary duty of care should be combined with the legal methodology of argumentation and reasoning, to clarify the order of application of norms, and to correctly apply the legal principles of concretization and weighing in order to strengthen the legitimacy and stability of the adjudication of the fiduciary duty of care.

【KEYWORDS】 trustees the duty of care class construction legal principle

目 录

问题的提出	1
一、受托人谨慎义务规范属性的法理基础	2
（一） 作为任意性规范的经济分析	2
1. 信托契约论的理论缘起与基本观点	2
2. 任意性谨慎义务的经济功能：降低交易成本与代理成本	3
（二） 作为强制性规范的道德论证	3
1. 信托契约论的类比失当与价值失范	4
2. 强制性谨慎义务的道德功能：作为有效社会规范与公共利益	4
二、受托人谨慎义务规范内容的阶层构造	6
（一） 意定性规范：信托文件条款的效力与限度	6
1. 信托文件约定谨慎义务的效力体现	6
2. 信托文件约定谨慎义务的免除限度	7
（二） 任意性规范：信托行业规范性文件	8
（三） 强制性规范：信托法中的一般条款	9
1. 英国“不可减损之核”理论的确立	9
2. 《信托法》第 25 条第 2 款的原则式诠释	10
三、受托人谨慎义务规范适用的方法重塑	12
（一） 谨慎义务规范适用的司法困境	12
（二） 谨慎义务规范适用的方法重塑：一个方法论的视角	12
1. 谨慎义务规范的适用顺序	13
2. 谨慎义务原则的具体化与权衡	14
结 论	16
参考文献	17

问题的提出

信托受托人谨慎义务（duty of care of trustees）^①，是指受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。谨慎义务是信托信义义务的重要一维，与受托人忠实义务一起发挥着规制受托人行为、维护受托人权益的重要作用。在我国现行法的语境下，除《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）第25条第2款之外，其他法律、部门规章以及规范性文件同样尝试对受托人谨慎义务予以具体的指引。^②

然而，即使有立法上存有规定，受托人谨慎义务概念并未受到足够的重视，并且在理论与实践存在着双重困境。在理论研究方面，纵向上，就信托信义义务而言，学界重视忠实义务研究而轻视谨慎义务研究，有观点认为忠实义务才是受托人信义义务的核心，而谨慎义务是否为信义义务的独特类型还有待探究，对谨慎义务的规范属性与规范内容尚不清晰；^③横向上，就其他法律关系中的谨慎义务而言，学界对谨慎义务的探讨多集中于侵权法、公司法领域，特别是后者中董事对公司的谨慎义务，对受托人谨慎义务的研究往往止步于简单的比较，在具体内涵与理论构建上尚不充分。^④在司法实践方面，对于受托人是否违反谨慎义务而承担赔偿责任的说理较为恣意，^⑤没有清晰稳定的裁判标准，甚至资管纠纷中多用合同法来替代信托法裁判说理，尚未厘清谨慎义务中法定与意定的边界。^⑥

随着资管新规落地，打破“刚兑”政策的持续施行，可以预见的趋势是，投资者以资产管理人违背受托人谨慎义务（特别是投资失败的情况下）为由，提起违信损害赔偿的诉讼势必增多。^⑦上述两重困境会直接影响司法裁判的尺度与稳定，不利于法律的安定性。就此而言，本文将尝试从理论建构与法律适用两个角度供给解决方案。本文第一部分着重探究受托人谨慎义务的法理基础，运用经济分析与道德论据归纳提炼谨慎义务的规范属性；第二部分，结合规范属性，进一步阐释受托人谨慎义务的规范构造，提供一个谨慎义务规范群的理论全景；第三部分，将上述理论构造经由法学方法论转换为司法适用方法，提出有关谨慎义务规范群的方法论适用模式，以期助益相关案件的司法裁判；最后简要做结。

① 关于术语选择问题，对于谨慎义务这一概念，相关表达还有“善管义务”“勤勉义务”“注意义务”等，均对应于英美法上的“Duty of Care”，本文无意于纠结概念文本的形成与内涵，仅在尊重实证法的基础上选择了与信托法第25条表述相同的“谨慎义务”。

② 较典型的如《中华人民共和国证券投资基金法》第9条，《信托公司管理办法》第24条，银保监会《关于信托公司风险监管的指导意见》，中国信托业协会《信托公司受托责任尽职指引》等。

③ 参见杨秋宇：《信托受托人忠实义务的功能诠释与规范重塑》，载《法学研究》2023年第3期；徐化耿：《信义义务的一般理论及其在中国法上的展开》，载《中外法学》2020年第6期。

④ 近有学者主张董事的谨慎义务与受托人的谨慎义务性质完全不同，前者属于普通法规则，而后者属于衡平法规则，参见邢海宝、李东阳：《董事谨慎义务：从信义法回归》，载《现代法学》2024年第1期。

⑤ 孙红庆：《资产管理人是否谨慎勤勉：裁判标准及构建路径》，载《经贸法律评论》2023年第4期。

⑥ 杨秋宇：《〈信托法〉的合同化适用倾向及其应对》，载《湖南农业大学学报(社会科学版)》2018年第6期。

⑦ “资管新规”是指《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号），关于诉讼趋势预测的论证，参见本文第三部分。

一、受托人谨慎义务规范属性的法理基础

就受托人谨慎义务规则而言，最核心的理论争议即是，作为法律规范的谨慎义务究为强制性规范（Mandatory Rules）抑或任意性规范（Default Rules）？^①前者不允许当事人之间协议排除，必须强制适用；后者在缺少当事人合意时作为对法律关系的进一步补充，但允许当事人合意排除或进行修改。与合同法相比，信托法的规范属性显得难以判断：在讨论合同法的规范属性时，人们尚可借助法律文本的指引进行判断，例如，当看见某个民法典条文的末尾附有一句经典的“当事人约定的除外”，我们立即明白该规范为任意性规范。而有关受托人谨慎义务的法律文本缺少类似表述——仅《信托法》第30条受托人的亲力义务，规范文本中有“但信托文件另有规定……”的但书。这当然不意味着除此之外的谨慎义务均为强制性规范，它仅仅是一种立法上的沉默，但这同时说明无从通过文义解释来探明其规范属性。^②

所以，需要进一步探究的是，在信义法上区分强制性规范与任意性规范的实质理由是什么？而要回答这个问题必须深入到信义义务规范的背后，探寻其规范目的，从而结合法理探讨其规范属性。其中，对谨慎义务的经济分析，以及在其基础上的价值批判最为重要，前者支持受托人谨慎义务作为任意性规范，后者则认为应当存有一定的强制性。以下综合考察这些法理基础，探讨受托人谨慎义务规定的规范属性。

（一）作为任意性规范的经济分析

1. 信托契约论的理论缘起与基本观点

美国法学教授 Langbein 在《耶鲁法律评论》上发表了一篇以契约类比信托的论文，开创了信托契约说的先河。他认为，信托本质上是一种第三方受益人合同（Third Party Beneficiary Contract），是有关如何管理与处分信托财产的一场交易（deal）或者讨价还价（bargain）。他的主要理由有三点：^③

第一，从历史的角度来看，信托法有从财产法向合同法演进的历史进程。信托产生之初的主要功能是规避封建税赋，保有封建土地，更多体现了财产法的色彩；等到了十七世纪末到十九世纪初期，对封建不动产的限制逐渐放开，作为财产转移手段的信托开始遇冷，而以财富管理为目的信托开始兴起，信托的目的从古代的转让演变为了现代的管理（From Conveyance to Management）。

第二，从功能的角度来看，信托与合同具有内在功能的对应关系。信托可以视为一种暗示的合同条款，发挥补充交易细节，降低交易成本的功用。尽管一直有观点在强调信托的道德修辞功能^④，但是不容否认的是信义义务在确定当事人之间的权利义务时，仅仅体现为当事人的某种合意。因此，信托在功能上可被视作合同。

第三，从比较法的角度来看，缺少信托法传统的大陆法系依靠合同法来处理信义法相关的问题。《海牙公约》的官方报告中指出，在没有信托法的法系，通常将信义关系按照合同关系处理，在民法法系的主流观点也认为，信托极具灵活性（flexibility），其当事人通常被

① 关于“Default Rules”的术语翻译问题，“Default Rules”最早是有关计算机系统的一个专业名词，被首先翻译为“缺省规则”，实为错译，应翻译为“默认规则”，本文为了与“强制性规范”相区分，采“任意性规范”的翻译，亦能契合传统民法的规范分类。参见桑本谦：《缺省规则与法律背后的合约》，载《现代法学》2020年第5期。

② 关于任意性规范的具体类型与识别方法，参见王轶：《论合同法上的任意性规范》，载《社会科学战线》2006年第5期。

③ John H. Langbein, *The Contractarian Basis of the Law of Trusts*, 105 *The Yale Law Journal* 625 (1995).

④ Robert Charles Clark, *Agency Costs versus Fiduciary Duties*, in John W. Pratt & Richard J. Zeckhauser eds, *Principals and Agents: The Structure of Business*, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1985, p.55.

视为合同关系。^①

Langbein 的观点引起了剧烈的反向。在资产管理行业蓬勃发展的背景下，法院只在产生纠纷时消极地介入信托关系，合同关系最真实地描述了职业受托人与客户的心态，受托人“受人钱财，替人理财”，似乎与某些委托合同已经大相径庭。所以在大多数时候，当事人都会产生以“信托就是信托文件”为核心的“信托契约综合征”。^②信托契约论因为符合业内真实情景而极具解释力。

2. 任意性谨慎义务的经济功能：降低交易成本与代理成本

信托契约论不仅从宏观的角度给出了信托契约化的图景，也从微观角度论证了信托契约化的具体功用。

首先，受托人的任意性谨慎义务能够降低交易成本。^③以此观点审视信托关系，信托当事人之间可视为经济学意义上的不完备契约，此时信义义务就充当了补充解释原契约的角色。^④特别地，谨慎义务出于防止受托人消极怠工的目的，为原合同提供了判别受托人是否需要承担损害赔偿责任的依据。结果是，委托人在与受托人达成信托合意后，无需再行列明受托人的行为清单与结果预期，也就减少了缔约的时间与难度，达到了降低交易成本的目的。^⑤

其次，受托人的任意性谨慎义务能够减少代理成本。^⑥对信托进行经济分析的学者借鉴了公司法学者的研究进路，将信托法中的信义义务类比公司法上的信义义务，进而引入代理成本理论。典型者如 Stikoff 教授认为，在将管理权配置于受托人而将剩余索取权配置于受益人的过程中，信托法应尽量减少固有的代理成本，但前提是这样做符合委托人的事先指示。^⑦其中，任意性谨慎义务能够起到将剩余管理权配置给受托人的作用，同时能够降低这个过程代理成本，“这些代理成本产生于受托人的漠不关心，缺乏适当管理信托资产的激励。通过强加责任于受托人以避免其失职，激励受托人适当谨慎而不是偷懒。”^⑧

出于以上两种经济功能的考虑，信托契约论者们认为，受托人谨慎义务规则应是任意性规范。

（二）作为强制性规范的道德论证

应当承认，利用经济分析研究信托法律关系是有益的，信托的经济功能前所未有地真实了起来。但是，契约论者们并未取得压倒性的胜利，受托人谨慎义务并不能被断言为纯粹的

① Adair Dyer & Hans van Loon, Report on Trusts and Analogous Institutions, in 2 HAGUE Conference, at 10, 1.

② 刘鸣炜：《信托制度的经济结构》，上海远东出版社 2014 年版，第 37 页。

③ 在制度经济学的语境下，交易成本（transaction cost）是指交易中所需支出的成本，主要表现为发现并利用价格机制的成本。See R. H. Coase, The Nature of the Firm, 4 Economica 386 (1937). 为了达成交易并尽可能减少交易成本，交易双方会考虑以某些长期合作的方式减少磋商次数或者降低谈判难度，例如签订长期契约，建立雇佣关系，合并企业等。不完备合同理论进一步认为，在这种持续的长期关系（“大合同”）中，虽然减少了每次缔约所需的交易成本（“小合同”），但是这个长期关系中的当事人不可能被面面俱到地约定彼此的行为，这个契约关系一定是不完备的。See Sanford J. Grossman & Oliver D. Hart, The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, 94 Journal of Political Economy 691 (1986).

④ Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, Contract and Fiduciary Duty, 36 The Journal of Law and Economics 425 (1993).

⑤ R. Cooter and B.J. Freedman, The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences, 66 N.Y.U.L.

Rev.1045(1991). 信托也可降低信托当事人外部关系的交易成本，参见王文字：《信托法原理与商业信托法制》，载《台大法学论丛》第 29 卷第 2 期。

⑥ 代理成本是一个经济学上的术语，最经典的含义包括三个部分，第一，为了使代理人（agent）以委托人（principle）利益最大化为目标行事，委托人可以加强对代理人的监督，这部分成本称为监督费用（monitoring costs）；第二，委托人还可以提高对代理人的激励，例如给予更高薪酬或者设置赔偿条款，这部分成本称为履约支出（bounding expenditures）；第三，即使这样，委托人仍然可能因为代理人的不当行为而造成损失，这部分成本称为剩余损失（residual loss）。See M.C.Jesen and W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure, 3 J. Finan.Econ.305(1976).

⑦ Robert H. Sitkoff, An Agency Costs Theory of Trust Law, SSRN Electronic Journal (2003).

⑧ 刘鸣炜：《信托制度的经济结构》，上海：上海远东出版社，2014 年，第 49 页。

任意性规范，一些强有力的理道德由反驳了上述论断，这些理由超越了经济学上的效率论据，从规范的角度就信托的本质作出了重要的判断，避免了信托彻底沦为合同的附庸。换言之，信托因其独有的道德特性而具有一定的强制法属性。

1. 信托契约论的类比失当与价值失范

类比是契约论者研究信托经济分析的主要进路，也是他们得出重要结论的基础。契约论者不厌其烦地将信托类比为合同，或者类比为公司进而类比为合同，本质上的推理过程都是一样的，即因为信托具有与合同相同的特征，所以信托规范也应当与合同规范具有相同的规范属性。表面上看，这种归纳推理因其方式易于复制、内容易于理解而具有某种正当性，但事实上这种归纳推理具有严重的问题，就受托人谨慎义务这一点而言，存在着类比失当与价值失范的双重危险。

形式上，以信义义务类比合同义务的推理基础是错误的。第一，信义关系的当事人并非合同关系的当事人。在同一个信托中，信托关系包括信托合同关系与信托信义关系，信托合同关系的当事人是委托人与受托人，而信托信义关系的当事人则是受益人与受托人。两组关系有所联系，但也相对独立，例如，受益人并不完全听命于委托人的事前安排，受益人可提前终止信托（放弃受益权），在某些特定情况下可以违背委托人的意愿行使信托权利（例如我国信托法第49条）；^①第二，信义关系的主体间并不具有合同关系主体间的平等地位。民法的理论假设是，作为民事主体的当事人之间具有完全相同的能力；而信义义务依靠信赖关系而生，当事人之间完全是不平等的关系，主要体现为能力和专业技能的不平等；第三，信义关系中的客体信赖并不等同于合同中的客体合意。事实上，两者唯一的共同点可能在于当事人之间存在“同意”，而在这基础上，合同法的规范目的是维护合意，平衡双方权利义务，使之尽可能对等，因此合同法上讲究“对价”；而信托法则强调保护委托人的信赖，维护受益人的权利，进而限制受托人的自由裁量权。^②

实质上，信义义务与合同义务的背后有着不同的价值考量。合同义务维护的价值是意思自治，其哲学立场是利己主义；而信义义务维护的价值是委托人的信赖利益，其哲学立场是利他主义。^③不同的价值考量决定了权利义务的不同配置方式，民法中的理性人，可以通过反复的磋商机制与法律的默认规则，达成最终的合意（包含推定的合意），实现意思自治；而信托法中的当事人则预设的是不完整理性人，其不完整理性的原因来自于对受托人的完全依赖，亦即“信而有托”，故法律应当倾斜保护之，为其划定一定的“自留地”，控制受托人的裁量权，以完善信任关系，实现信托中的道德功能。

2. 强制性谨慎义务的道德功能：作为有效社会规范与公共利益

信托契约论对受托人谨慎义务的研究，仅着眼于信托当事人之间，并没有考虑到信义义务关系的外部性。事实上，虽然在法律层面，由于信义义务的相对性，它仅会影响到信托当事人之间的权利义务，但是从社会事实层面观察，每一对信义义务关系的生成，都会影响整个社会系统的信义义务标准；而每一对信义义务内容的差异，都可能造成对社会共识的偏离，这种外部性偏差是信托契约论者没有考虑到的。

首先，受托人谨慎义务并不只是一种法律规范，更是一种社会道德规范。美国公司法学者 Eisenburg 在研究公司法规范时，将公司法中的信义义务规范视为一种义务性道德规范（obligational norms）。他认为，许多义务规范都具有内化效力，内化的规范将成为个人道德的一部分，个人会条件反射地遵守它，即使这样做会导致他们放弃物质利益；然而，规范也

① [英] 阿拉斯泰尔·哈德逊：《衡平法与信托的重大争论》，沈朝晖译，北京：法律出版社，2020年，第59页。

② Tamar Frankel, Fiduciary Duties as Default Rules, 74 OR. L. REV. 1209 (1995).

③ 赵廉慧：《论信义义务的法律性质》，载《北大法律评论》2020年第1期。

是可以改变的，如果有足够多的人认为其他人违反了规范，那么规范就会达到“临界点”，失去其强制力。^①“如果受托人认为其他受托人经常违反社会规范，那么将这些规范内化的受托人就会减少，而会在考虑是否采取机会主义行为时进行成本效益分析。”^②对受托人谨慎义务的彻底任意化，将减少此种社会共识，从而降低受托人对自身行为的谨慎要求，这种要求并非法律上的威慑，而来自于道德的拘束，后者总是更加持久有效的。

其次，受托人谨慎义务并不只关注私人利益，它同时体现为一种社会公共利益。当受托人群体频繁地修订信托谨慎义务时，作为公共利益的谨慎义务默认共识就会被削减。从微观视角来看，每一对信托当事人合意修改谨慎义务条款之时，谨慎义务的集体共识就会发生偏离。随着时间的推移，放弃共识的负外部性逐渐暴露出来，信托当事人之间随意地约定，不再参考某种潜在的标准，此时受托人谨慎义务沦为合同条款的附庸，不再附有任何道德教化的作用，亦与其期望的降低交易成本的目标相去甚远。^③换言之，此时的受托人谨慎义务丧失了其公共性，不再具有道德模板与标准合同的参考作用，而当事人也将会为寻找普遍标准付出更多的交易成本。

综上所述，基于经济与道德的不同理由，受托人谨慎义务的规范属性表现为：原则上为任意性规范，但同时具有一定的强制性。

① Melvin Aron Eisenberg, Corporate Law and Social Norms, 99 COLUM.L.REV.1253, 1273-75 (1999)

② Melanie B. Leslie, Trusting Trustees: Fiduciary Duties and the Limits of Default Rules, 2005. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=711849>.

③ Melanie B. Leslie, Trusting Trustees: Fiduciary Duties and the Limits of Default Rules, 2005. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=711849>.

二、受托人谨慎义务规范内容的阶层构造

规范属性明晰之后，进一步需要讨论的是规范内容。受托人谨慎义务表现出任意性与强制性的兼容，那么究竟哪些是任意性规范，哪些是强制性规范？这两种规范又者靠怎样的方式组合出谨慎义务的最终样态？显然，这种区分与组合不再单纯由经济功能或者道德论据决定，而与现行法规定、法系演化和教义学传统息息相关。因此，本部分将结合信托法原理与我国的法律实践展开具体的教义学构建。

除了任意性与强制性的区分标准之外，对于谨慎义务规范尚需注意到意定性与法定性的分别。逻辑上，如果将当事人的约定视为一种法律渊源，意定性与法定性的区分应在任意性与强制性的区分之前——只有法定性的规范才进一步区分为任意性规范与强制性规范，而意定性规范在有效的情况下则具有优先适用的地位。

本文认为，受托人谨慎义务并非独立的概念存在，而是一个具有阶层构造的规范群，按照适用顺序，谨慎义务规范群具体可表现为意定性规范、任意性规范与强制性规范的组合。这个规范群的生成并非静态不居，而是表现为法秩序与当事人间意思自治的动态耦合，这也正是谨慎义务兼具抽象性与灵活性的体现。故因此，本文界定的规范阶层构造，如下图所示，以下分别论述：

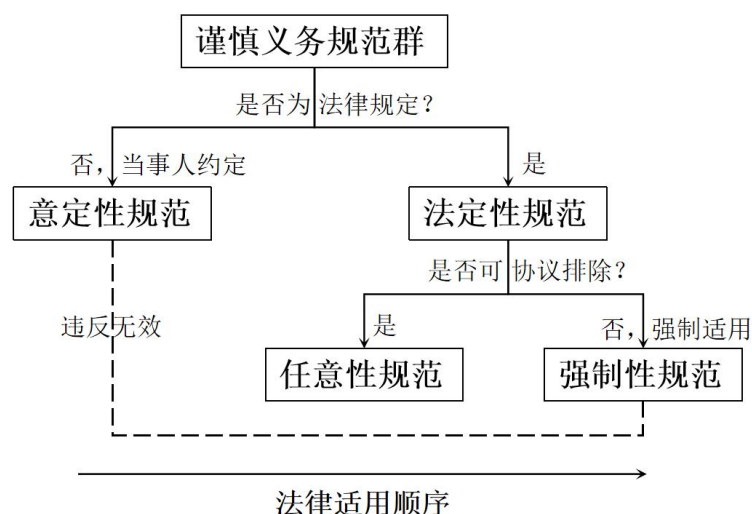


图 1

（一）意定性规范：信托文件条款的效力与限度

信托关系中的意定性规范，主要表现为信托文件中的具体条款。这些条款既可以选出信托法中的规范，也可以排除信托法部分规范的适用，还可以创设不同于信托法规定的权利义务。本部分主要考察信托文件条款的效力与限度，作为谨慎义务规范群中的意定部分，信托文件发挥着意思自治的重要作用，但同时也受到法秩序的效力检验。

1. 信托文件约定谨慎义务的效力体现

谨慎义务虽是法定义务，但法定的是义务性质，而非义务的具体内容，当事人仍然可以通过约定将法定义务具体化。^①

^① 赵廉慧：《作为民法特别法的信托法》，载《环球法律评论》2021年第1期。

首先，信托文件可以约定受托人谨慎行事的标准。一般认为，在缺乏信托文件的情况下，不同的受托人将对应着不同的标准，“若受托人具有（或声称具有）高等或特殊的技能或知识，则该受托人有一位（即‘注意义务’要求其）将该特殊技能或能力运用出来。”^①也就是说，当存在“普通—特殊—职业”受托人水平的划分时，他们的谨慎义务标准也会因此而呈现出阶梯式的不同，但是当存在约定的情况下，当事人可以通过信托文件对受托人的谨慎义务标准加以调整，对其减轻抑或加重，例如对普通受托人提出严苛的职业标准，或是降低职业受托人的谨慎程度，前提是其减轻不至于低于最低限度。

其次，信托文件可以约定受托人谨慎行事的后果。受托人违反谨慎义务，造成信托财产毁损灭失或者价值减损的，应当承担赔偿责任。此种责任是法定责任，在当事人之间没有约定的情况下，赔偿范围以恢复原状与填补损失为准。不过，信托文件可以约定赔偿范围与赔偿方式，当信托文件存在约定时，在不违反强制性规范的前提下，以信托文件约定的赔偿责任为准。

2. 信托文件约定谨慎义务的免除限度

信托并不是合同，当事人的约定效力有其限度。无论是选出、创设抑或排除，在尊重当事人意思自治之前，最关键的问题仍然是，该规定是否违反信托法上的强制性规范。进言之，信托法有其最低限度的强制性义务，当事人对此并无选出自由，不得将其排除，也不能创设与之冲突的权利义务。所以，本部分关注的重点是，当事人约定免除受托人谨慎义务的限度。值得注意的是，逻辑上，似乎应当区分受托人义务免除与受托人免责，^②但是法律效果上，两者并无实质异同，本文对二者作相同处理。^③

在比较法上，美国的信托成文立法与法律重述对免责条款有着较为详细的规定，从中我们可窥见免责条款的现代立法样板。美国《统一信托法》（Uniform Trust Code, UTC）是美国统一州法委员会会议（The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, NCCUSL）起草通过的一部有关信托的模范立法，被称为“美国信托法的首次全国性全面编纂”。^④它虽然没有法律效力，但是可作为各州的立法参考，对美国各州的信托立法产生了重大影响。其中，第105条为“任意性规则与强制性规则”（Default and Mandatory rules），意在揭示信托法各条文的规范属性，该条（b）项规定了14种优先适用情形，即14种强制性规范。^⑤涉及免责的条款的有5项，该5项即为不可免责条款，当事人不得约定免除与之相关的义务与责任。^⑥UTC第1008条为“受托人免责”，该条进一步规定了免责条款的效力。^⑦可见，UTC对免责条款效力的态度比较温和，一方面，只有涉及强制性事项的免责条款才有可能无效；另

① [美] 爱德华·C. 哈尔巴赫：《吉尔伯特信托法》，张雪梅译，北京：法律出版社，2017年，第210页。

② Restatement (third) of Trusts §96 cmt. a (Tentative Draft No. 5, 2009). 同时参见[日] 新井诚：《信托法》（第四版），刘华译，中国政法大学2017年版，第208页。

③ 在“义务—责任”的法理逻辑下，只有违反了义务，才有可能承担责任。换言之，违反义务是承担责任的基础。就受托人而言，违反信托义务后免责，一般指免除损害赔偿赔偿责任，但受托人仍需因违反信托义务，而承担减少薪酬、甚至解聘的不利影响。但是也应当看到，义务与责任紧密相关，没有义务的责任是虚幻的，而没有责任的义务则是无力，英美学者在研究信托约定免除时，通常将义务免除与责任免除等而视之，重点均放在信托义务的可排除性上，参见汪怡安、楼建波：《信托受托人免责条款效力探析——美国法的立场及其启示》，载《盛京法律评论》2020年第1期。

④ John H. Langbein, Mandatory Rules in the Law of Trusts, 98 Nw. U. L. REv. 1105 (2004).

⑤ Uniform Trust Code §105.

⑥ 它们分别是第（2）“项受托人善意（good faith）或根据信托目的行为的义务”；第（3）项“信托及其条款应有利于受益人的要求，信托目的应合法而不与公共政策违背且有实现可能”；第（8）项与第（9）项的信息披露义务；第（10）项“第1008条规定的免责条款的效力”。参见肖百灵：《论信托文件中免责条款的效力——美国法的经验和中国法的借鉴》，载《南昌大学学报(人文社会科学版)》2010年第2期。

⑦ See Uniform Trust Code §1008. 该条由两部分组成，第一部分描述了两项无效的免责条款情形，即“恶意（bad faith）或无视（reckless indifference）信托目的或受益人利益”与“滥用信义或信赖关系”两种情形不得免责；第二部分描述了免责条款无效的原则与例外，原则上由受托人起草滥用信义关系的免责条款无效，除非满足两个要件，第一，受托人证明该条款的公平性；第二，受托人已明确告知委托人。

一方面，即使涉及强制性事项，受托人也可以通过证明该条款的公平性与充分告知受托人来重新获得豁免。^①

美国的立法经验表明，免责条款原则上有效，而例外无效。具体可概括为两点：第一，免责条款违反信托法的强制性规定时无效，而这种强制性规定一般体现为兜底性质的法律原则；第二，受托人存在恶意行事或者滥信义义务行为时，免责条款无效。但此种无效并不绝对，受托人可以通过证明程序与告知程序维系免责条款效力。

我国究竟应采取何种理论进路，可以结合美国经验，通过解释论予以确立。信托法通过后，全国人大常委会法工委的相关人员出台了《中华人民共和国信托法释义》，该释义并非全国人大常委会的立法解释，不具有法律效力，但是作为立法者出品的解释性文件，可以认为是立法者主观目的的表达。其中，在第25条的释义中写道：“本条规定的受益人最大利益原则和诚实、信用、谨慎、有效管理信托财产的义务，是法定的原则和义务，受托人不得违反。如果违反上述原则和义务，受托人就要承担故意或重大过失的责任，对这种责任，当事人不能约定免除。”^②由此可见，立法机关即认为，违反了受托人谨慎义务的基本原则，需对故意或重大过失负责，此时，受托人可谓非善意，其责任不得被约定免除。换言之，从方法论的角度而言，通过主观目的解释，探寻立法者的真意，此种解释方案构建了一种善意的判断方式，即“故意或重大过失”即为“恶意行事”，此时受托人的不得免责。

总之，意定性规范虽然在适用上具有优先性，但其是否有效则取决于是否违反强制性规范。作为合同条款的谨慎义务规范自然需要考虑是否违法、违背公序良俗、意思表示是否真实等所涉的法律行为效力问题，而作为信义条款的谨慎义务，则需要进一步考虑是否违反信托法上有关信义义务的一般条款，即是否违反谨慎义务规范群中的强制性规范。

（二）任意性规范：信托行业规范性文件

当信托文件不能对当事人权利义务作出具体指引时，意味着此时信托关系出现了漏洞，需要法官进行漏洞填补的司法工作。而法官的自由裁量并非随心所欲，特别地，法官不能用自己的商业判断代替他人的商业判断，否则有司法裁判过度介入商事关系之嫌。此时，如何正确地填补漏洞成为了重要的问题。

本文认为，在我国，有关受托人谨慎义务的大量规范，事实上散见在各式各样的行业规范性文件中。^③这些规范性文件上至法律、行政法规，下至部门规章、狭义规范性文件，不仅对受托人的行为提出了具体的要求与指引，而且反映了信托行业的普遍共识与行为标准，以之为裁判依据或者裁判参考兼具专业性与正当性。

具体而言，第一，信托法律中存在谨慎义务的任意性规范。《信托法》中存在着广义的谨慎义务规范，例如第29条、第30条、第33条，分别规定了受托人的分别管理义务、亲力义务、信息披露义务、保密义务。这些义务只涉及信托内部关系，且并不影响到信托的本质功能，未触及信托的强制性规范，故上述义务均可作为信托文件所约定排除，具有任意性。

第二，信托相关的部门规章中存在着对特定受托人谨慎义务的法定具体化。例如，《信

① 另一个重要的文件是美国法律协会（ALI）编纂的信托法重述（Restatement of Trusts），目前已经修订至第三版。作为美国信托法上最权威的学术解读，信托法重述与 UTC 具有协同合作的关系，联系十分紧密。就受托人谨慎义务而言，第三版重述的第96节与 UTC 第1008条的表述类似，不同之处在于，重述中对受托人不得豁免的主观态度要求，从 UTC 的无视（reckless indifference）降低为了忽视（indifference），且扩充了判断受托人主观状态依据。可见，该规定相对于 UTC 而言，进一步提高了对受托人义务豁免的要求以及对受益人的保护力度。See Restatement (third) of Trusts §96 cmt. a (Tentative Draft No. 5, 2009); See Louise L. Hill, Fiduciary Duties and Exculpatory Clauses: Clash of the Titans or Cozy Bedfellows, 45 U. MICH. J. L. REFORM 829 (2012).

② 卞耀武主编：《中华人民共和国信托法释义》，北京：法律出版社，2002年，第96页。

③ 有观点也认为，对信托法上谨慎义务的规定，应当采取“概括与具体相结合”的立法模式。参见周乾：《中国信托业刚性兑付的法律成因、影响与对策》，载《内蒙古社会科学（汉文版）》，2016年第3期。

托公司管理办法》第四章“经营规则”，《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四章“信托计划的运营与风险管理”，均有大量有关谨慎义务的具体化规定。作为职业受托人的信托公司，在《信托法》的规定之外，需遵守更加细密的监管规定，但在对受益人信义义务的私法层面，相关规范并不绝对具有强制性，而是首先表现为任意性，是否具有强制性需要结合信托法第25条第2款进行决断。^①

第三，一些行业规范性文件具有更加明确的指引性，能够作为谨慎义务内容的重要参考。虽然规范性文件法源层级较低，法官不得直接援引裁判，但是这些行业规范性文件凝聚了业内共识，使得法官在判断受托人是否尽责时有了更加清晰的标准。^②

（三） 强制性规范：信托法中的一般条款

对于受托人谨慎义务，是否存在不得扣减的“禁区”？从规范论的角度来看，此即意味着，是否存在有关受托人谨慎义务的强制性规范？作为信托法的发源地，英国最早讨论了这个问题，其理论演变可以给我们一定启示。

1. 英国“不可减损之核”理论的确立

在信托理论界，英国的 Hayton 教授率先主张，受益人的执行权与受托人的信义义务是信托的核心，而“善意行事”（act in good faith）则是信义义务中的“不可减损之核”（The Irreducible Core Content of Trusteeship）。换言之，信义义务中诚信、善意地实施信托事宜的义务，不得被约定免除。^③理由是，如果作出这样的约定，信托将被架空而不再被视为由信赖而生的法律关系，法院也将因此不再认可信托法律关系，从而使受托人免受司法的处理。

不久后，英国和威尔士上诉法院法官 Millett L.J. 在 Armitage v. Nurse 案中采纳了 Hayton 教授的观点，在判决中他如此写道：“受托人对受益人负有不可减损的核心义务，而且这些义务可由受托人强制执行，这是信托概念的根本所在。如果受益人没有可以对受托人强制执行的权利，那么信托也就不存在了。……为了受益人的利益，受托人诚实和善意地履行信托，是使信托具有实质内容所必需的最低限度义务。”^④此后，信托义务“不可减损之核”理论成了英国信托法针对信义义务免除问题的基本立场。

Hayton 与 Millett L.J. 的观点可以被概括为三点：第一，虽然信托具有一定的合同基础，但是信托存在不可减损的核心义务；第二，这个核心义务就是“善意行事义务”（good faith），

① 存有疑问的是，监管性质的规范，是否属于谨慎义务的来源？本文认为，监管规范并不当然视为有关谨慎义务的强制性规范。首先，对监管规范的识别，应当伴随着对规范目的识别：如果监管目的并非受益人利益的保护，那么该监管规范就不是谨慎义务的来源；如果此时监管规范实为保护性规范，此时监管规范属于谨慎义务来源，但其性质为强制性还是任意性仍需进一步判断。其次，所谓监管规定属于强制性规范，是就监管部门与受托人之间的法律关系而言，委托人与受托人之间的信托文件当然不能免除受托人的监管义务，违反监管义务，受托人应当承担相应的监管责任，但这种责任表现为公法责任（行政责任或者刑事责任），但并不代表当事人之间不能协议豁免相关私法责任。进言之，就受托人是否当然承担私法责任而言，在存在免责条款的基础上，还需要考察受托人在行为发生时是否善意行事、受益人应受保护的程度以及相应的政策目的等因素综合判断，最终还是需要回到信托法第25条第2款的适用上。因此，在区分公法责任与私法责任的前提之下，并非违反监管规范一定会对受益人承担赔偿责任，所以，监管规范并不当然都是受托人谨慎义务的强制性规范，仅可作为使用信托法第25条第2款的内容参考，这也体现了监管秩序与私法秩序的二元划分格局。

② 例如，2014年银保监会发布的《关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发[2014] 99号）中表明：“信托公司应切实履行受托人职责，从产品设计、尽职调查、风险管控、产品营销、后续管理、信息披露和风险处置等环节入手，全方位、全过程、动态化加强尽职管理，做到勤勉尽责，降低合规、法律及操作风险”，这七个尽责实际上即是对信托公司谨慎义务的细化与参考；2018年中国信托业协会制定的《信托公司受托责任尽职指引》的“第四章 运营管理”集中规定了作为受托人的信托公司的行为规范与义务要求，参见赵廉慧：《论信义义务的法律性质》，载《北大法律评论》2020年第1期。

③ David Hayton, The Irreducible Core Content of Trusteeship, in A J Oakley ed., Trends in Contemporary Trust Law, Oxford University Press, 1997, p.47-62.

④ Armitage v. Nurse [1998] Ch. 241

而不及于技能、谨慎、注意和勤勉的义务（duties of skill and care, prudence and diligence），也即不包括广义的谨慎义务（duty of care）；第三，除了“善意行事义务”，其他谨慎义务均可被约定免除。

可以说，“不可减损之核”理论首次给出了明确了信托法谨慎义务是否可约定免除的界限，换言之，它给出了我们判断某谨慎义务是否为任意性或强制性的标准。这个标准表明，善意行事义务是谨慎义务中的强制性规范。^①

2. 《信托法》第25条第2款的原则式诠释

我国是否需要参照英国的“不可减损之核”理论设置受托人谨慎义务的强制性规范？这需要结合我国信托法的具体规定加以判断。一般认为，我国《信托法》第25条第2款规定了我国信托受托人的谨慎义务。^②该款规定：“受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。”本文认为，结合本文第一部分的法理分析，一定程度的强制性规范有助于降低负外部性，最大化发挥其经济功能与道德功能。而我国谨慎义务的应然设置模式，既不是通过判例确立强制性谨慎义务的判别标准，也不是在立法文本中写明的具体强制性情形，而是可以通过法律原则来进行概括与审查。这种原则性诠释具体可以拆解为四个部分。

首先，在规范分类上，《信托法》第25条第2款并非法律规则，而是法律原则。一个完整的法律规则，一般由明确的构成要件与法律后果构成；^③法律原则与之相反，表现出一种宽泛的规定与抽象概括，需要具体化后再行适用。《信托法》第25条第2款中未提及具体的构成要件或者法律后果，也不与其他条文组成完整规范链条，但是在其他信托法规则适用困难的时候，能够进行具体化并加以司法裁判，解决疑难案件，这正是法律原则的功能体现。^④

其次，在规范属性上，《信托法》第25条第2款并非任意性法规范，而是强制性规范。作为《信托法》受托人谨慎义务的一般条款，该条体现了谨慎义务的普遍功能与基本要求，事实上，该款中“诚实信用”的表述已经实质蕴含了英国法上“善意行事”的要求。如前所述，通过考察立法机关的本意，本条对不可豁免的情形具有强制性。其背后的法理在于，作为兜底性质的谨慎义务基本原则，其功用并非在于事前填补漏洞，乃在于事后定分之争，所谓的法律原则的填补功能（修正功能），本质上是在已经产生纠纷的情况下，法律根据价值判断进行权利配置，此种配置并不体现为当事人之间的意思自治，而是体现为法秩序的基本标准与一般伦理要求，因此具有强制性。但是，在内容上，对于第25条第2款，本文主张应当对“恪尽职守”与“谨慎有效”进行限缩解释：“恪尽职守”“谨慎有效”均不直接承诺信托结果，而是强调在信托存续期间受托人行为达到“善意管理”（good faith）的程度即达到了谨慎义务原则的基本要求。亦即满足了信托的强制性要求，其余的谨慎义务可由双方在信托文件中任意约定。^⑤我国民法上的诚实信用原则可以作为受托人谨慎义务原则解释建构的参考。^⑥

① 随着有关“不可减损之核”理论研究的不断深入，一些学者也认为，在受托人逐渐专业化的今天，对受托人谨慎义务的“不可减损之核”标准应当提升，除善意行事义务之外，应当包括狭义的谨慎义务。参见 Rebecca Lee & Man Yip, *Exclusion of Duty and the Irreducible Core Content of Trusteeship: A Re-Assessment*, *Journal of Equity* 10 (2020).

② 赵万一主编：《信托法学》，北京：高等教育出版社，2022年，第104-106页，该部分由王涌教授写作。

③ 雷磊：《法律规则的逻辑结构》，载《法学研究》2013年第01期。

④ 有观点认为，《信托法》第25条第2款实际上是一般条款，并尝试区分一般条款与法律原则，一般条款为法律原则的下位概念，除一般条款外，法律原则尚且包括倡导性法律原则，参见徐化耿：《资产管理人勤勉尽责义务的理论基础与司法适用》，载《现代法学》2023年第3期。本文认为，一般条款与法律原则在法规范论层面具有相同的意义，即规定抽象，无具体构成要件与法律效果，这些特点均足以与法律规则相区分；所谓的倡导性法律原则其实并非法规范层面的法律原则，原因在于法律原则与法律规则的区分主要体现与适用方式，而非法律效果。所以，本文在相同意义上使用一般条款与基本原则的表述，只是两者侧重点有所不同：一般条款强调规范内容上的抽象性与宽泛性，而法律原则强调规范论本质与适用方式。

⑤ 我国立法者对该条的解释也印证了本文的观点。立法者认为，此处的“恪尽职守”是指职务注意，“诚实信用”是指善意履职，“谨慎”是指高度的注意力，“有效管理”是指效率最高，均指向执行信托事务的过程而非结果。参见全国人大信托法起草工作小组编：《〈中华人民共和国信托法〉释义》，北京：中国金融出版社，2001年，第83-84页。

最后，在体系构成上，《信托法》第 25 条第 2 款并非受托人谨慎义务的全部来源，而是谨慎义务规范群的一部分，与其他规范一起产生体系效应。强制性规范仅是受托人谨慎义务群的其中一层，特点是它的强度最大，表现为其他与之抵触的谨慎义务规范无效。原因在于，当事人的意思自治固然值得尊重，但是强制性规范作为法秩序的最低要求，体现的是整个社会的基本道德共识，所以其强度最高。其他的任意性规范，可在不触及该法律底线的层面进行权利配置。

值得注意的是，第 25 条第 2 款仅能提供主观性强制审查标准，至于客观强制性规范如何确定，值得深思。本文认为，所谓的客观强制性规范在现行法中无固定体现，与其说难以事前确定客观强制性规范的存在，毋宁说其实际上体现在事后综合认定。原因在于，客观强制规范更多体现出政策导向的色彩，而非学理构建。具体到司法适用，法院才裁判中也拒绝明确表明何种规范为具体的强制性规范，而是结合第 25 条第 2 款进行原则说理。因此，无论从主观还是客观方面而言，强制性规范的认定与适用均需回归到对信托法第 25 条第 2 款的论证展开之上。

综上所述，从规范强度与规范数量的角度，可以得到对受托人谨慎义务规范群的阶层构造进行进一步的具体呈现，如下图所示：

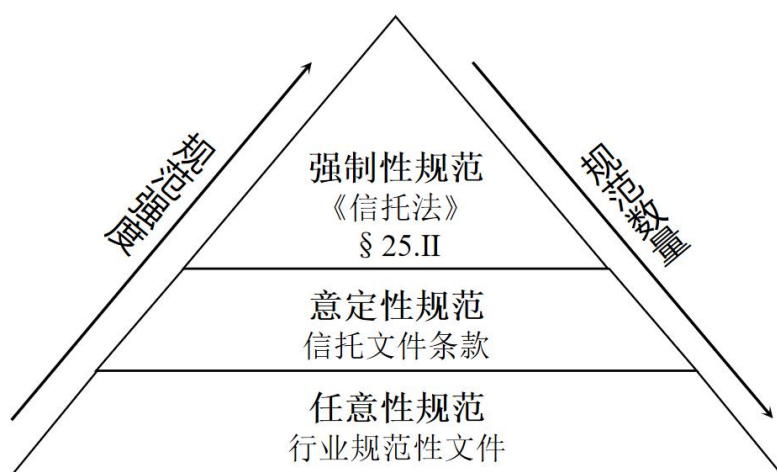


图 2

⑥ 参见赵磊：《信托受托人的角色定位及其制度实现》，载《中国法学》2013 年第 4 期；楼建波、姜雪莲：《信义义务的法理研究——兼论大陆法系国家信托法与其他法律中信义义务规则的互动》，载《社会科学》2017 年第 1 期。

三、受托人谨慎义务规范适用的方法重塑

（一）谨慎义务规范适用的司法困境

受托人谨慎义务并非只具有教义学意义，它也是司法裁判中的论证说理的重要对象。随着我国打破“刚兑”政策的施行，可以预见的变化是：当投资失败时，受益人（一般也是委托人）不能再根据“刚兑”条款要求受托人还本付息，那么有关的资产管理纠纷将大大增加，特别是受益人可能起诉受托人违反谨慎义务。^①原因在于，投资失败后的受益人总是想要寻求某些救济来抚平心理与经济上的创伤，而起诉受托人违反信托文件则是一件十分困难的事——一般来说，受托人在投资领域会比受益人拥有更丰富的理论知识与职业经验，面对接近于格式条款的信托文件，受益人起诉受托人承担违约责任将十分困难。此时，受益人会更倾向于起诉受托人违反信义义务，特别是谨慎义务：一方面，比起合同义务，信义义务并非全然约定，具有抽象宽泛的特质，容易结合具体案情论证，不会被信托文件（当事人约定）所限制；另一方面，之所以是谨慎义务而非忠实义务，主要是证明负担为题，对受益人而言，证明受托人违反了忠实义务是困难的，因为这需要受益人主动提供证据证明受托人实施过存在利益冲突的行为，而对于谨慎义务的证明则存在举证责任倒置，受托人需自证未违反义务。^②

面对着可能到来的纠纷热潮，目前我国受托人谨慎义务的司法适用尚未明确统一的裁判标准，缺乏论证说理，具有一定的随意性与盲目性：首先，在适用法律选取方面，比起主动适用信托法，法院更愿意适用合同法来判案，司法裁判出现“信义义务条款被《合同法》诚信条款取代、信义义务被视为合同义务、合同法免责条款用于规避信义责任等现象”^③；其次，在义务约定排除方面，法院显示出摇摆不定的裁判态度，“一方面，法院倾向于认可排除受托人尽职调查、事先投资审核义务的信托合同条款效力，表明了不过度干预信托合同安排的裁判立场。……另一方面，有法院认为受托人的信托资金来源审查义务、投资项目尽职调查义务、信托财产监管义务不可被当事人协议排除，表现出了对受托人信义义务排除限制甚至是否定的立场。”^④最后，在论证说理方面，在法律没有规定或者约定不明情况下，法院判决受托人违信责任承担与否的论证说理不够细致，论证不够具体。然而，如果没有具有说服力的规则供给，也难以形成一个稳定的商事司法秩序，受托人的义务清单也因为被置于司法黑箱中而模糊不清。

（二）谨慎义务规范适用的方法重塑：一个方法论的视角

① 事实也同样符合预期，信托纠纷类案件数量越来越多，呈现出增长的趋势，参见何海锋：《国枫观察 | 信托纠纷的新趋势》，载微信公众平台，

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDY0MzM4Ng==&mid=2649424415&idx=2&sn=d2f039a3f50874c0da9e00e0325cbb2f&chksm=87fbb94ab08c305cb438ccfb3a6c62ce22d70784d82f3b50d078cd82b07eae5da6538f504a95#rd，2024年4月18日访问。该文根据作者在北京信托法学研究会成立大会暨“信托业转型发展及信托法制完善”研讨会上的与谈发言整理而成。

② 《全国民商事会议纪要》第94条 资产管理产品的委托人以受托人未履行勤勉尽责、公平对待客户等义务损害其合法权益为由，请求受托人承担损害赔偿责任的，应当由受托人举证证明其已经履行了义务。受托人不能举证证明，委托人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院依法予以支持。

③ 详细的实证分析参见唐仪萱、刘琦：《《信托法》信义义务规则司法适用“弱势”困境的实证分析》，载《四川师范大学学报(社会科学版)》2023年第5期。

④ 熊敬：《受托人信义义务排除的限度——以被动管理型信托为视角》，载《湖南科技大学学报(社会科学版)》2022年第6期。认同约定条款的案例参见最高人民法院(2020)最高法民终488号判决书，湖北省高级人民法院(2017)鄂民终2301号判决书，最高人民法院(2017)最高法民终880号判决书；不认同的案例参见上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民初80151号民事判决书，山东省高级人民法院(2020)鲁民终2633号判决书。

本文认为，上述司法困境产生的根源在于对受托人谨慎义务的内容认识不足，没有把握住谨慎义务的规范群本质及其法律推理模式。本部分将从方法论的视角，以法律适用为切入点，提供一种受托人谨慎义务规范群的适用方法。

1. 谨慎义务规范的适用顺序

由本文第二部分可知，受托人谨慎义务概念并非单一适用的法律概念，而表现为一个阶层式构造的规范群，这个规范群按照强度高低具体可分为强制性规范、意定性规范与任意性规范。而在法律规范的适用层面，根据经典的法学方法论，法律规范还有一种分类，即按照规范的逻辑结构与适用方式进行分类，分为法律原则与法律规则。如前所述，我国信托法上的强制性规范，信托法第 25 条第 2 款是法律原则。我国信托法上的意定性规范与任意性规范，因其通常规定了当事人之间具体的权利义务，具有完整的构成要件与法律效果，而构成法律规则。所以，结合方法论的新分类，我国的信托受托人谨慎义务规范群的阶层构造，可以进一步阐释为如下组合，即强制性原则、意定性规则与任意性规则。

下图为谨慎义务规范群的适用顺序：

	规范属性	规范类别	规范来源	适用顺序
《信托法》§ 25.II	强制性	原则	法定	兜底适用
信托文件条款	任意性	规则	意定	优先适用
行业规范性文件	任意性	规则	法定	补充适用

图 3

(1) 法律规则优先于法律原则

在同时存在法律原则与法律规则时，法官应当优先适用法律规则。原因在于，法官具有依法裁判的基本义务，而其中的“法”首先指向明定的法律规则集群。如果法官无视法律规则集群而径行适用法律原则，这种“向一般条款逃逸”（*Flucht in die Generalklauseln*）的行为违背了依法裁判的基本要求。^①换言之，在适用法律原则之前，依法裁判的理念要求法官首先遍历全部法律规则，如果此时尚不能实现公正的结果，那么，法官需要“在逻辑上先确定存在制定法漏洞”^②，再行尝试适用法律原则以实现个案正义。这背后的法理在于，司法自由裁量权应当承担论证法律漏洞的负担，以免侵扰立法民主。^③

这就要求，在受托人谨慎义务相关案件裁判时，如果信托文件条款或者行业规范性文件中对相关行为有所规定，那么法官不得仅依靠信托法第 25 条第 2 款进行原则式说理，而应当结合信托文件与行业规范性文件的具体规定，论证受托人是否违反谨慎义务。否则，法官径行自由裁量，本质上是对当事人信托文件所表现的意思自治的侵害，也是对行业规范性文件的法源地位的无视，违背了法官依法裁判义务的基本要求。^④

① Vgl. Justuswilhelm Hedemann, *Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Recht und Staat*, Tübingen: Mohr, 1933, S. 76. 转引自 [德] 托马斯·M. J. 默勒斯：《法学方法论》（第四版），北京大学出版社 2022 年版，第 416 页。

② [德] 卡尔·拉伦茨：《法学方法论》（第六版），北京：商务印书馆，2020 年，第 504 页。

③ 从另一个角度，法律规则可以视为法律原则的特别规定，而特别法将优先于一般法适用。法律原则作为法秩序的内在体系的表达方式，是一种“实质的法律思想”，是价值判断的标准以及法律规则内生性的源头，[德] 卡尔·拉伦茨：《法学方法论》（第六版），商务印书馆 2020 年版，第 593 页。这种观点不乏实在法支撑，根据《立法法》第 103 条规定的“特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定”以及《民法典》第 11 条规定的“其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定”，法律规则优先与法律原则适用应当是实在法的应有之义。

④ 另外，从化解纠纷的角度来说，直接适用原则说理的说服力太弱，当事人不能得到翔实准确的司法回应，将明显提升上诉意愿；此外，由于原则说理供给的论证理由过少，市场缺乏足够的司法预期，也会因此增大交易的不确定性，使默认的谨慎义务标准发生偏离，影响信托行业发展。

以“陈明与光大兴陇信托有限责任公司等侵权责任纠纷案”（“光大信托案”）为例，^①一审判决书在论证受托人的谨慎义务时，并未径直适用法律原则，而是首先结合了《银监会关于印发信托登记管理暂行办法的通知》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条等规范性文件，论证了受托人应具有的登记、调查的法定谨慎义务，进而再论证其侵权行为与损害赔偿，具有较强的合理性与说服力。

（2）意定规则优先于法定规则

在同时存在意定规则与法定规则时，法官应当优先适用意定规则。原因在于，任意性规则的适用，与法秩序和法伦理无关，故应当首先保护当事人之间的意思自治。对此，我国《信托法》第28条禁止双方代理与第30条受托人亲力义务中，均含有“但受托文件另有规定”的特殊情况，表明了任意性规则适用中意定规则先与法定规则的适用顺序。同时，这两条可作为适用其他规范性文件的类推基础，将意定规则优先适用于法定规则的法理逻辑扩展到所有谨慎义务中，以充分保障当事人之间的规范合意，规范性文件仅作为补充规范予以适用。这就要求，在判断受托人是否违反谨慎义务时，须先通过信托文件的约定，判断是否满足受托人行为是否满足信托文件的最低要求，而不能径直适用规范性文件。当事人在信托文件中约定了高于规范性文件的要求，例如按约定平仓、分散投资等，法院须以高要求作为受托人是否违信的判断依据；而如果当事人在信托文件中约定的义务要求低于规范性文件，例如降低尽职调查的义务、无须主动管理（消极信托），法院则须以低要求为标准作出裁判。^②

以“某农村商业银行诉某信托公司营业信托纠纷案”为例，^③法院在论证受托人的谨慎义务之前，首先结合案涉《信托合同》《尽调报告》《股权收益权转让与回购合同》等当事人约定，尝试证成受托人谨慎义务的特殊性，最终界定受托人为“非典型主动管理型信托”，进而确定受托人的谨慎义务范围及违反责任，体现了谨慎义务规范群中“意定优先于法定”的适用方法。

2. 谨慎义务原则的具体化与权衡

如果当事人的信托文件缺少相关的约定，规范性文件中也未明确提及具体情形，此时需要法院行使自由裁量，结合信托法谨慎义务原则进行裁决。这种决断虽然没有具体的规则指引，但是也并毫无章法可言。有学者提出，信义义务的司法适用可借鉴比例原则理论。^④本文认为，从方法论的角度出发，在只有受托人谨慎义务原则得以适用的情况下，应当通过具体化与权衡两种方式进行法律适用，所谓的比例原则，其实是原则权衡理论的一个特殊形式。^⑤

首先，形式上，应当通过具体化，将原则转换为可以涵摄适用的规则。具体化是指将抽象的法律原则应用到具体的案例或情境中，以便更清晰地理解和适用法律规则。在具体化过程中，法律原则会根据具体的事实和情况进行解释和运用，以确保法律规则能够有效地适用于具体案例，具体化有助于法律规则更具体、更实际地指导法律实践。这就要求，法官在审理具体的受托人谨慎义务纠纷时，需要对原则适用展开充分说理，对“构成要件”与“法律效果”进行具体化阐释，以便进行涵摄推理。法官裁判受托人违反谨慎义务原则时，可以采取以下的三种步骤：第一，法官应当结合案件具体事实，查明相关的违信行为；第二，还应当考察此时一个谨慎的受托人应当采取何种注意程度，此时可以结合案件的具体情况以及行业惯习进行充分论述，避免以“司法裁判标准”代替“行为标准”；^⑥第三，应当充分检视可

① 参见北京市朝阳区人民法院(2019)京0105民初87359号民事判决书。

② 值得注意的是，上述规范顺序的适用前提为，意定性规则不与强制性原则冲突，否则，意定性规则将归于无效。而作为任意性规则的行业规范性文件，有其严格的立法程序，而且通常是上位法授权立法，故一般不会与强制性原则相冲突。

③ 参见上海金融法院(2022)沪74民初204号民事判决书。

④ 徐化耿：《信义义务的一般理论及其在中国法上的展开》，载《中外法学》2020年第6期。

⑤ [德]罗伯特·阿列克西：《法：作为制度的理性化》，雷磊译，北京：中国法制出版社，2012年，第150页。

⑥ 孙红庆：《资产管理人是否谨慎勤勉：裁判标准及构建路径》，载《经贸法律评论》2023年第4期。

能的失信抗辩，包括但不限于当事人知情同意、信托条款约定豁免、客观商业风险等。

其次，实质上，应当将相关的原则进行权衡，以最值得保护的原则为解释基准。原则作为一种“最佳化命令”，依靠权衡而非涵摄进行适用；^①而权衡是指在适用法律原则时需要权衡不同的法律原则分量，以适用最应实现的原则。在某些情况下，不同的法律原则可能会发生冲突，此时需要进行权衡来确定哪种原则应当优先适用。德国法学家阿列克西认为，权衡的核心在于“权衡法则”，它可以被表述为：“一个原则的不满足程度或受损害程度越高，另一个原则被满足的重要性就必须越大。”^②在受托人谨慎义务的纠纷裁判中，此时的原则冲突，表现为受益人利益原则与受托人自由裁量原则的冲突。这就要求，法官在居中裁判时，充分衡量这两种原则在具体案件中的被满足/受损害程度，判断最能实现个案正义的法原则“胜出”。例如，如果此时受益人利益原则更值得保护，则判决受托人违反谨慎义务；反之如果此时受托人管理自由原则更加值得青睐，则判断受托人并无失信行为。

以“吴某诉华澳国际信托有限公司财产损害赔偿纠纷案”（“华澳信托案”）为例，^③本案争议焦点主要集中于通道信托（消极信托）受托人的谨慎义务范围，具体为：第一，华澳信托公司是否有义务核查信托资金来源；第二，华澳信托公司是否有义务对信托产品所涉项目开展尽职调查；第三，华澳信托公司是否有义务对信托财产进行监管。最终法院认定，受托人具有核查义务与调查义务，而无监管义务。判决书的说理大意为，核查义务与调查义务涉及到刑事犯罪，受托人“未对犯罪分子借用其金融机构背景进行资金募集的行为采取必要防控措施，也未对社会投资者作相应警示”，未尽到合理注意义务，且对犯罪分子集资诈骗行为的客观帮助，此时吴某作为犯罪受害人，理应获得更高的利益保护；而监管义务标准较高，且合同未约定此项义务，所以受托人不承担财产监管风险，无须履行监管义务。可见，法院在谨慎义务的范围划定上进行了法律原则的适用，对所涉当事人进行了利益权衡，有助于增强判决的公信力。^④

① 雷磊：《为权衡理论辩护》，载《政法论丛》2018年第2期。

② Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1996, 71ff. 这个过程可以被重述为三个步骤：第一，确认原则A的受损程度；第二，确认与之冲突的原则B被满足的重要性；第三，证成原则B被满足的重要性是否优先于对原则A的损害。

③ 参见上海金融法院（2020）沪74民终29号民事判决书。

④ 遗憾的是，该案未能充分展示原则衡量的过程，使得判决书说理缺乏规律性与稳定性。

结 论

谨慎义务的概念不仅具有深厚的理论传统，更有着深刻的实践功用。仅仅依靠着对合同法与公司法研究进路的拙劣模仿，无法构建出符合法理的信托受托人谨慎义务体系。应当注意到，在“同案同判”的法治要求下，我国事实上拥有了类似判例法的裁判传统，但即使这样，也不应该放弃论证说理的方法论进路。本文提供了一种可能的思路：按照受托人谨慎义务的规范性质，从规范论的角度将该规范群体体系化，并提出一套符合方法论的司法适用方法。这种教义学框架能够帮我们更好地理解受托人谨慎义务的动态构成，且更适应大陆法系裁判的说理传统，具有裁判上的正当性与合理性。未来，法官能否做到合理使用受托人谨慎义务概念进行司法裁判，很大程度上并非取决于是否符合政策导向，或者是否接受类案指引，而是取决于是否进行了妥当的教义学作业，即充分的规则选取与原则权衡。

参考文献

- [1] 卞耀武主编. 中华人民共和国信托法释义[M]. 北京:法律出版社, 2002: 96.
- [2] 雷磊. 法律规则的逻辑结构[J]. 法学研究, 2013, 35(01): 66-86.
- [3] 雷磊. 为权衡理论辩护 [J]. 政法论丛, 2018, (02): 23-33.
- [4] 刘鸣炜. 信托制度的经济结构[M]. 上海:上海远东出版社, 2014: 37, 49.
- [5] 楼建波, 姜雪莲. 信义义务的法理研究——兼论大陆法系国家信托法与其他法律中信义义务规则的互动 [J]. 社会科学, 2017, (01): 92-102.
- [6] 全国人大信托法起草工作小组编. 〈中华人民共和国信托法〉释义[M]. 北京:中国金融出版社, 2001: 83-84.
- [7] 桑本谦. 缺省规则与法律背后的合约 [J]. 现代法学, 2020, 42 (05): 17-34.
- [8] 孙红庆. 资产管理人是否谨慎勤勉:裁判标准及构建路径 [J]. 经贸法律评论, 2023, (04): 108-124.
- [9] 唐仪萱, 刘琦. 《信托法》信义义务规则司法适用“弱势”困境的实证分析 [J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2023, 50 (05): 65-74.
- [10] 王轶. 论合同法上的任意性规范 [J]. 社会科学战线, 2006, (05): 229-235.
- [11] 王文字. 信托法原理与商业信托法制 [J]. 台大法学论丛, 2000, 29(02): 309-416.
- [12] 汪怡安, 楼建波. 信托受托人免责条款效力探析——美国法的立场及其启示 [J]. 盛京法律评论, 2020, 08(01): 63-122.
- [13] 肖百灵. 论信托文件中免责条款的效力——美国法的经验和中国法的借鉴 [J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2010, 41 (02): 55-60.
- [14] 邢海宝, 李东阳. 董事谨慎义务: 从信义法回归 [J]. 河北法学, 2024, 42 (01): 37-58.
- [15] 熊敬. 受托人信义义务排除的限度——以被动管理型信托为视角 [J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2022, 25 (06): 102-110.
- [16] 徐化耿. 信义义务的一般理论及其在中国法上的展开 [J]. 中外法学, 2020, 32 (06): 1573-1595.
- [17] 徐化耿. 资产管理人勤勉尽责义务的理论基础与司法适用 [J]. 现代法学, 2023, 45 (03): 138-149.
- [18] 杨秋宇. 《信托法》的合同化适用倾向及其应对 [J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2018, 19 (06): 68-73.
- [19] 杨秋宇. 信托受托人忠实义务的功能诠释与规范重塑 [J]. 法学研究, 2023, 45 (03): 149-167.
- [20] 赵磊. 信托受托人的角色定位及其制度实现 [J]. 中国法学, 2013, (04): 74-86.
- [21] 赵廉慧. 论信义义务的法律性质 [J]. 北大法律评论, 2020, 21(01): 62-86.
- [22] 赵廉慧. 作为民法特别法的信托法 [J]. 环球法律评论, 2021, 43 (01): 68-84.
- [23] 赵万一主编. 信托法学[M]. 北京:高等教育出版社, 2022: 104-106.
- [24] 周乾. 中国信托业刚性兑付的法律成因、影响与对策 [J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2016, 37 (03): 90-96.

- [25]朱圆. 论信托免责条款的法律效力 [J]. 法学, 2019, (09): 43-56.
- [26] [德] 罗伯特·阿列克西. 法: 作为制度的理性化[M]. 雷磊, 译. 北京:中国法制出版社, 2012: 150.
- [27] [美] 爱德华·C. 哈尔巴赫. 吉尔伯特信托法[M]. 张雪樑, 译. 北京:法律出版社, 2017: 210.
- [28] [日] 新井诚. 信托法(第四版) [M]. 刘华, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2017 年: 208.
- [29] [英] 阿拉斯泰尔·哈德逊. 衡平法与信托的重大争论[M]. 沈朝晖, 译. 北京:法律出版社, 2020: 59.
- [30] Adair Dyer & Hans van Loon, Report on Trusts and Analogous Institutions [R]. in 2 HAGUE Conference.
- [31] David Hayton, The Irreducible Core Content of Trusteeship [C]// A J Oakley ed., Trends in Contemporary Trust Law [M], Oxford University Press, 1997: p.47-62.
- [32] Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, Contract and Fiduciary Duty [J], 36 The Journal of Law and Economics 425 (1993).
- [33] John H. Langbein, Mandatory Rules in the Law of Trusts [J], 98 Nw. U. L. REv. 1105 (2004).
- [34] John H. Langbein, The Contractarian Basis of the Law of Trusts [J], 105 The Yale Law Journal 625 (1995).
- [35] Louise L. Hill, Fiduciary Duties and Exculpatory Clauses: Clash of the Titans or Cozy Bedfellows [J], 45 U. MICH. J. L. REFORM 829 (2012).
- [36] M.C.Jesen and W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure [J], 3 J. Finan. Econ. 305 (1976).
- [37] Melanie B. Leslie, Trusting Trustees: Fiduciary Duties and the Limits of Default Rules [J], 2005. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=711849>.
- [38] Melvin Aron Eisenberg, Corporate Law and Social Norms [J], 99 COLUM. L. REV. 1253, 1273-75 (1999).
- [39] R.Cooter and B.J. Freedman, The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences [J], 66 N.Y.U.L. Rev. 1045 (1991).
- [40] Rebecca Lee & Man Yip, Exclusion of Duty and the Irreducible Core Content of Trusteeship: A Re-Assessment [J], 10 Journal of Equity (2020).
- [41] R. H. Coase, The Nature of the Firm [J], 4 Economica 386 (1937).
- [42] Robert H. Sitkoff, An Agency Costs Theory of Trust Law [J], SSRN Electronic Journal (2003)
- [43] Robert Charles Clark, Agency Costs versus Fiduciary Duties [C]// John W. Pratt & Richard J. Zeckhauser eds, Principals and Agents: The Structure of Business [M], Harvard Business School Press, 1985: p.55.
- [44] Sanford J. Grossman & Oliver D. Hart, The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration [J], 94 Journal of Political Economy 691 (1986).
- [45] Tamar Frankel, Fiduciary Duties as Default Rules [J], 74 OR. L. REV. 1209 (1995).
- [46] Justus Wilhelm Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Recht und Staat [M], Tübingen: Mohr, 1933: p.76.
- [47] Robert Alexy, Theorie der Grundrechte [J], 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1996.